

1501163-16.2022.8.26.0536
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Alexandre Torres de Aguiar
Comarca: São Vicente
Foro: Foro de São Vicente
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 18/08/2022
... sentido:

"Apelação - Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria bem demonstradas - Testemunho dos agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa - Ré confessa, ademais - Não incidência do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que não preenchidos os requisitos subjetivos - Precedentes - Pena de multa que se corrige - Mínimo erro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Vicente
Foro de São Vicente
1ª Vara Criminal
Rua Jacob Emmerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501163-16.2022.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501163-16.2022.8.26.0536
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Réu:
VAGNER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR e outro

Prioridade Idoso
Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Torres de Aguiar

Vistos.

PEDRO HENRIQUE BRITO DA SILVA SANTOS e VAGNER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 70 do mesmo diploma legal, porque, no dia 25 de março de 2022, por volta das 11 horas, na Avenida Getúlio Vargas, próximo ao numeral 261, no bairro Gonzaguinha, nesta cidade, em ocasião de calamidade pública, agindo previamente acordados e com unidade de desígnios com outros indivíduos não identificados, mediante grave ameaça, subtraíram para si próprios coisas móveis pertencentes a C.S.T. e N.A.S.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo, em via pública próxima à "Biquinha", nesta cidade, em ocasião da calamidade pública, agindo previamente

acordados e com unidade de desígnios com outros indivíduos não identificados, mediante grave ameaça, subtraíram para si próprios coisas móveis pertencentes J.A.M.G.

Recebida a denúncia, os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação.

Em audiência, foram ouvidas as vítimas e as testemunhas arroladas na denúncia. Ao final, foram os réus interrogados.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação dos réus pelos crimes descritos na denúncia, diante da prova produzida. Pleiteou a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com o reconhecimento das circunstâncias agravantes relativas à calamidade pública e por terem sido os crimes cometidos contra pessoas maiores de 60 anos de idade. Requereu, ainda, o reconhecimento da reincidência quanto ao acusado Wagner, e a aplicação da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas quanto a ambos os réus. Pediu o reconhecimento do concurso formal quanto aos crimes praticados contra as vítimas C. e N. e o reconhecimento do concurso material destes crimes com aquele praticado contra a vítima J. Finalmente, requereu a fixação de regime inicial fechado.

A Defesa do acusado Wagner pugnou por sua absolvição, por falta de provas quanto à autoria. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base em seu mínimo legal, com o afastamento da circunstância agravante relativa à calamidade pública.

A Defesa do acusado Pedro Henrique, por sua vez, requereu sua absolvição, por falta de provas. Subsidiariamente, quanto à dosimetria da pena, requereu a fixação da pena-base dos crimes em seu mínimo legal, bem como o afastamento da circunstância agravante relativa à calamidade pública. Pediu, outrossim, a não aplicação da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade dos delitos de roubo restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 9/10, pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 11/12, bem como pela prova oral colhida em Juízo e demais elementos amealhados aos autos.

A autoria, contudo, somente é certa quanto ao acusado Pedro Henrique.

Interrogados em Juízo, os acusados negaram a prática dos crimes descritos na denúncia.

Vagner disse que seguia para a praia com um indivíduo de nome Gabriel, a quem estava levando em sua bicicleta, e, ao atravessarem uma ponte, policiais os abordaram e informaram que seriam levados à delegacia para averiguação. Declarou que foram levados em viatura até outro local, onde estava o corréu Pedro Henrique, a quem não conhecia anteriormente à prisão, e os três, juntos, foram levados à delegacia, onde soube ter sido reconhecido pelas vítimas. Disse que nada foi encontrado consigo ou com Gabriel. Não soube se o corréu Pedro Henrique participou dos roubos.

Pedro Henrique alegou que havia saído de um treino na “Biquinha” e viu muitos indivíduos correndo. Contou que estava de bicicleta e viu dois policiais aproximando-se em sua direção e estes passaram por onde estava, mas, então, um dos policiais retornou e o abordou, dizendo que o levaria à delegacia para averiguação. Disse que, após algum tempo, uma viatura chegou ao local de sua abordagem com outros três indivíduos e foi conduzido à delegacia nessa mesma viatura. Contou que

o acusado Vagner era um dos indivíduos que estavam no veículo, e não o conhecia anteriormente aos fatos. Não soube se Vagner e os demais indivíduos que ali estavam participaram dos roubos. Alegou que um daqueles indivíduos tinha o cabelo tingido como o seu, mas ele não foi reconhecido pela vítima e foi liberado.

Entretanto, a negativa do acusado Pedro Henrique e a versão por ele apresentada estão isoladas no conjunto probatório amealhado.

As vítimas, quando ouvidas sob o crivo do contraditório, confirmaram ter sido roubadas e bem descreveram como se deu a ação criminosa.

J.A.M.G. declarou que estava caminhando em direção à Ponte Pênsil quando dois indivíduos de bicicleta passaram à sua frente, pararam e olharam para trás em sua direção. Disse que, nesse momento, com receio de sofrer um roubo, tentou retornar para trás, porém outros três indivíduos já se aproximaram em bicicletas. Relatou que, ao todo, cinco indivíduos o abordaram, sendo que um deles postou-se à sua frente, dizendo que estava armado e anunciando o roubo, enquanto dois deles o revistaram, e dois permaneceram às suas costas. Narrou que um dos meliantes que o revistou começou a retirar a aliança de seu dedo e pediu que ele parasse, para que pudesse retirar sozinho e evitar machucar-se. Disse que outro roubador que o revistou, subtraiu de seu bolso o valor de R\$30,00. Consignou que seu aparelho celular estava dentro da bermuda, atrás de seu corpo, e não foi encontrado pelos meliantes que, em posse de seu dinheiro e de sua aliança, evadiram-se na direção da Ponte Pênsil. Declarou que, após o roubo, acionou a polícia por ligação ao "190", comunicando o roubo e indicando a rota de fuga dos cinco assaltantes. Relatou que, passados dez a quinze minutos, foi informado por telefone que indivíduos haviam sido detidos, sendo solicitado seu comparecimento ao local da abordagem para reconhecimento. Disse que uma viatura policial o conduziu até a Ponte Pênsil, onde, para evitar sua exposição aos indivíduos que ali estavam contidos, lhe foram mostradas fotografias em um celular, e reconheceu as duas pessoas retratadas como sendo os dois meliantes que o haviam revistado e lhe subtraído seus pertences. Narrou que lhe foram mostradas duas alianças e reconheceu uma delas como sendo de sua propriedade. Disse que também lhe foi mostrado um bolo de dinheiro, mas informou aos policiais que de sua propriedade haviam sido subtraídos apenas R\$30,00. Declarou que, na sequência, foi à delegacia, onde realizou o reconhecimento formal de dois dos três indivíduos que ali estavam identificados por folhas numeradas, esclarecendo que os dois meliantes apontados eram aqueles que o haviam revistado e tomado sua aliança e seu dinheiro. Esclareceu que o indivíduo que anunciou o roubo, dizendo estar armado, não estava entre os capturados. Relatou que, na delegacia, soube que um casal que ali estava também havia sido roubado no mesmo caminho na direção da Ponte Pênsil, mas não soube os autores do crime eram as mesmas pessoas. Declarou que reconheceu dois dos indivíduos detidos na delegacia pelas características físicas de ambos que pode visualizar no momento do crime, pois eles foram os que se aproximaram para revista-lo e subtrair seus bens. Consignou que os meliantes que reconheceu eram jovens, magros, com pele morena, e um deles estava com um cabelo tingido e trajava bermuda sem camisa. Em Juízo, reconheceu apenas o acusado Pedro Henrique como sendo um dos indivíduos com mais semelhança a um dos roubadores.

C.S.T. declarou que estava passeando com seu marido, usando seu aparelho celular para registrar imagens do local, quando, repentinamente, cerca de três ou quatro indivíduos os abordaram dizendo "perdeu, perdeu". Relatou que, de pronto, entregou seu aparelho celular aos meliantes, e um destes abocanhou seu dedo onde estavam sua aliança e seu anel de brilhante, machucando-a enquanto os puxava. Disse que os anéis estavam justos e pediu calma ao roubador, até que conseguiu retirar os objetos de seu dedo. Narrou que, nesse ínterim, outro meliante segurou seu marido, a vítima N., rasgando sua camisa e subtraindo dele dinheiro e a aliança. Declarou que os fatos ocorreram de forma rápida e, em posse de seus bens, os roubadores evadiram-se do local em bicicletas. Disse que, após o roubo, foi até um local onde

havia um guarda, para pedir ajuda, mas, logo em seguida, soube que policiais já haviam detido alguns indivíduos. Relatou que os policiais informaram que o dinheiro e a aliança de seu marido haviam sido encontrados, porém os bens de sua propriedade haviam sido jogados em um mato e não foram recuperados. Narrou que, entre uma e duas horas após os fatos, foi à delegacia, onde visualizou três ou quatro indivíduos por um visor, reconhecendo um deles como um dos autores do delito. Esclareceu que a pessoa que reconheceu tinha o cabelo descolorido e pode melhor memorizar sua fisionomia. Consignou que o indivíduo que reconheceu não foi aquele que pegou seus pertences e não recordou qual foi a conduta exata por ele praticada, mas afirmou que ele era uma das pessoas que integrava o grupo de assaltantes que os abordaram e roubaram. Narrou que não foi agredida pelos meliantes, porém um deles colocou seu dedo na boca para puxar sua aliança, machucando-o. Em Juízo, apontou Vagner como sendo uma das pessoas que se assemelhava a um dos autores do delito e esclareceu que o indivíduo que reconheceu em solo policial tinha o cabelo tingido, não conseguindo identifica-lo entre aqueles apresentados para reconhecimento.

N.A.S. declarou que estava com sua esposa em local próximo à “Biquinha” quando foram abordados por indivíduos que se aproximaram de bicicletas e já passaram a subtrair seus bens. Relatou que, de sua propriedade, foram subtraídas a aliança e a quantia de R\$70,00 que estava em seu bolso. Narrou que, após o roubo, foram à delegacia para realizar o registro da ocorrência e soube que indivíduos já haviam sido detidos por policiais logo após o roubo, pois os mesmos meliantes teriam praticado roubo contra outra vítima, que os havia acionado. Disse que, na delegacia, os bens de sua propriedade lhe foram restituídos. Relatou que os fatos ocorreram rapidamente e não conseguiu visualizar direito os roubadores, porém viu que um deles, que pegou sua aliança e seu dinheiro, tinha o cabelo colorido. Não recordou qual o traje este indivíduo estava vestindo, pois olhou mais para seu rosto e para seu cabelo. Declarou que, na delegacia, foram apresentados três indivíduos para reconhecimento, mas somente conseguiu identificar um deles, sendo o que tinha o cabelo tingido. Disse que no local dos fatos não havia muita circulação de pessoas ou de automóveis. Em Juízo, não conseguiu reconhecer os acusados dentre os indivíduos apresentados para reconhecimento.

A testemunha policial militar Edson Thadeu Vanzuita da Silva, ouvida em Juízo, relatou que realizava patrulhamento quando foram noticiados roubos a transeuntes, em que os meliantes estavam em bicicletas. Declarou que, durante patrulhamento com vistas a estes meliantes, ao entrar na Rua Newton Prado, viu que indivíduos que ali estavam, ao verem a equipe policial, retornaram repentinamente. Consignou que, diante desta conduta, bem como das características dos indivíduos que haviam sido noticiadas, foi realizada a abordagem. Relatou que abordou uma daquelas pessoas, enquanto seu parceiro seguiu acompanhando as demais e o perdeu de vista. Narrou que, com o indivíduo que abordou, localizou duas alianças, que pareciam ser de ouro, e a quantia de R\$214,00. Disse que, informalmente, o réu admitiu ter roubado algumas pessoas em local próximo à “Biquinha”. Declarou que seu parceiro, com apoio, realizou a abordagem de outros dois indivíduos, mas não presenciou esta ação. Disse que, após, as pessoas abordadas foram conduzidas à delegacia. Relatou que não contou quantos eram os indivíduos de bicicleta, mas esclareceu que eram vários e consignou ter visto um deles lançar algo em um terreno. Esclareceu que não foi possível acessar esse local para apurar o que ali havia sido dispensado. Disse que uma das vítimas esteve no local onde realizou a abordagem, e ela reconheceu o indivíduo que ali estava detido como um dos autores do crime. Não soube o resultado do reconhecimento realizado na delegacia e esclareceu que não acompanhou as declarações prestadas formalmente pelas vítimas. Declarou, sem certeza, que o indivíduo que abordou assemelhava-se ao acusado Pedro Henrique.

A testemunha policial militar Danilo de Oliveira Santos, ouvida em Juízo, relatou que realizava patrulhamento com seu parceiro, Sargento Vanzuita, quando foi anunciado roubo ocorrido próximo à Ponte Pênsil. Narrou que, em seguida, visualizou cinco indivíduos aproximando-se juntos em bicicletas e eles, ao verem a equipe

policial, mudaram de sentido, retornando na direção da “Biquinha”. Declarou que um daqueles indivíduos foi detido pelo Sargento Vanzueta, mas os demais empreenderam fuga, tendo três deles ingressado na Ponte Pênsil, sentido cidade de Praia Grande. Disse que um desses indivíduos conseguiu voltar e evadir-se, mas os outros dois foram abordados. Narrou que, com um destes homens abordados, foi encontrada uma quantia em dinheiro. Questionados estes dois sobre a razão da fuga, ambos admitiram, informalmente, a prática do roubo. Relatou que, em seguida, seu parceiro de farda anunciou que havia detido o outro indivíduo que ele havia abordado, com quem ele localizou grande quantidade de dinheiro e alguns objetos, dos quais não recordou. Relatou que manteve contato com as vítimas na delegacia e estas identificaram dois dos três indivíduos abordados como sendo autores do roubo. Não recordou os nomes dos indivíduos que abordou. Declarou que não acompanhou as declarações das vítimas na delegacia e não recordou se presenciou o ato formal de reconhecimento. Não recordou se, antes da condução à delegacia, foi feito contato com as vítimas ou se a elas foram mostradas fotografias.

Em face de toda a prova carreada aos autos, diante das declarações das vítimas e dos depoimentos das testemunhas policiais, os quais foram fornecidos com segurança e detalhes, não há dúvidas em se concluir que o acusado Pedro Henrique efetivamente participou dos delitos de roubos descritos na denúncia.

Os depoimentos das vítimas e das testemunhas policiais são coerentes e harmônicos entre si e se complementam, estando em consonância com suas declarações prestadas na fase extrajudicial.

Em relação ao depoimento da vítima em casos como o dos presentes autos, destacam-se os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

“A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta inocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si” (TACRIM-SP – AC – Rel. Almeida Braga – JUTACRIM 100/250)

“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer a do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos” (TACRIM-SP-AC-Rel. Celso Limongi-JUTACRIM 94/341).

Quanto ao testemunho dos agentes policiais, com enorme grau de confiabilidade, também prestam-se a viabilizar a condenação do acusado.

Em relação ao valor probatório do depoimento de testemunha policial destaca-se o seguinte entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

“É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte”. (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRADO REGIMENTAL NO AGRADO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 – Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011).

"Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais -Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em

juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF 1a Turma - HC n. 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189).

As três vítimas relataram semelhante dinâmica quanto aos roubos que sofreram. Declararam que vários indivíduos as abordaram, subtraindo seus pertences, inclusive suas alianças.

Narraram que, pouco após o roubo, tiveram notícia de que indivíduos haviam sido detidos por policiais e as vítimas J. e N. afirmaram que os bens que lhes foram subtraídos foram recuperados.

Disseram que, na delegacia, foi realizado procedimento para o formal reconhecimento de indivíduos detidos e cada uma das vítimas pode esclarecer quais e quantos indivíduos reconheceram, especificando a conduta praticada por aqueles meliantes durante a ação criminosa.

Assim, em Juízo, ressaltou a vítima J. que, em solo policial, reconheceu dois dos três homens apresentados, declarando que estes foram os participantes do crime que a revistaram, subtraindo sua aliança e seu dinheiro, e consignou que um desses indivíduos reconhecidos tinha o cabelo tingido naquela oportunidade.

A versão judicial da vítima J. mostra-se compatível com a documentação constante dos autos, em especial com o auto de reconhecimento de fls. 22, do qual se infere ter a vítima J. reconhecido ambos os réus, indicando que o acusado Pedro Henrique foi o indivíduo que se apossou de seus bens.

Frise-se que, ao contrário do alegado pela Defesa do acusado Pedro Henrique, a vítima J., embora demonstrando não ter ampla certeza, pode apontar Pedro Henrique como um dos indivíduos que se assemelhava a um dos roubadores que a abordaram. Esclareceu que as características do acusado, ao ser apresentado em Juízo, diferiam daquelas vistas na data dos fatos, uma vez que a pessoa que o abordou não estava com óculos e tinha o cabelo tingido.

Contudo, em que pese a dúvida manifestada pela vítima, depreende-se dos autos que o acusado Pedro Henrique realmente tinha seu cabelo tingido quando detido, o que se pode verificar pela fotografia de fls. 36 e pelo auto de qualificação de fls. 39.

Da mesma forma, a vítima C., em Juízo, esclareceu que o indivíduo que reconheceu na delegacia tinha o cabelo tingido e pode ver que ele foi um dos agentes que participou do crime, abordando-a e abordando seu marido, a vítima N. Afirmou, apenas, que esse indivíduo não foi o que diretamente subtraiu seus pertences pessoais, o que está em consonância com o descrito no auto de reconhecimento de fls. 14.

Já a vítima N. esclareceu que o homem por ela reconhecido tinha o cabelo tingido e foi aquele que se apossou de sua aliança e seu dinheiro, que foram recuperados e lhe foram restituídos.

Acresça-se às declarações das vítimas, o relato judicial da testemunha policial Edson. Narrou a testemunha que, ciente da notícia de roubo praticado por vários meliantes, viu indivíduos em bicicletas e, diante de suas características e de suas condutas em alterar o caminho ao ver a equipe policial, realizou a abordagem,

conseguindo deter um deles, com quem encontrou duas alianças e uma quantia em dinheiro e soube, posteriormente, ter sido reconhecido pelas vítimas como um dos autores dos crimes. A testemunha Edson pode indicar o acusado Pedro Henrique, em Juízo, como sendo o indivíduo que se assemelhava àquele que abordou.

Veja-se que as alianças apreendidas na data dos fatos com o acusado Pedro Henrique foram reconhecidas pelas vítimas J. e N. e a elas foram restituídas, como se verifica do auto de fls. 11/12.

A apreensão da res em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo a ele provar o contrário, o que não ocorreu.

A reunião de todos estes elementos traz, portanto, a certeza necessária quanto à participação de Pedro Henrique nos delitos descritos na denúncia.

Outrossim, a grave ameaça restou bem caracterizada.

As vítimas relataram de que forma o acusado Pedro Henrique e seus comparsas as abordaram, esclarecendo que vários foram os indivíduos que as cercaram para, de imediato, subtrair seus pertences.

Acrescentou a vítima J. que, na ação criminosa que a vitimou, um dos meliantes disse estar portando arma, enquanto outros dois a revistavam e subtraíam seus bens, e outros dois permaneciam às suas costas.

Consignou a vítima C., que os indivíduos que repentinamente a abordaram juntamente com seu marido N. diziam “perdeu, perdeu” e passaram a tomar-lhes os bens. Declarou que enquanto um dos meliantes tentava retirar os anéis de seu dedo com a boca, o que a machucou, a vítima N. foi contida, teve a camisa rasgada e, então, teve os bens subtraídos.

Dessa forma, não resta qualquer dúvida sobre a conduta do acusado Pedro Henrique que, mediante grave ameaça contra as vítimas, participou dos delitos de roubo.

Os roubos efetivamente se consumaram, uma vez que o réu e seus comparsas conseguiram apoderar-se da res, invertendo sua posse. Outrossim, quanto ao roubo que vitimou C.S.T., a res sequer foi recuperada.

Depreende-se, outrossim, do conjunto probatório amealhado aos autos, que a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas restou comprovada.

As vítimas afirmaram que vários foram os autores do crime. Dessume-se de seus depoimentos que o acusado Pedro Henrique e seus comparsas dividiram as tarefas no momento do crime, de maneira a executá-lo de forma mais eficiente, estando, portanto, bem demonstrada a majorante relativa ao concurso de agentes.

Finalmente, quanto aos crimes de roubo praticados contra as vítimas C.S.T. e N.A.S., é caso de aplicação das regras do concurso formal de delitos, nos termos do artigo 70 do Código Penal.

Depreende-se da prova produzida que o acusado Pedro Henrique e seus comparsas abordaram ambas as vítimas juntas e subtraíram bens de cada uma delas.

Nesse passo, destaca-se o seguinte posicionamento jurisprudencial:

TJSP: “Se através de uma só ação pratica o assaltante dois roubos à mão armada contra vítimas diversas, tem-se como configurado concurso formal de delitos, e não crime único.”(RT 563/321)

Já em relação aos crimes de roubo praticados contra estas vítimas, ocorridos em concurso formal, e o crime de roubo cometido contra a vítima J.A.M.G., é caso de reconhecimento de crime continuado.

Inferre-se dos autos que os roubos ocorreram durante um curto espaço de tempo, perpetrados na mesma região, e, nas duas ocasiões, com o mesmo modus operandi, sendo de rigor o reconhecimento da continuidade entre eles, nos termos do artigo 71 do Código Penal.

Todavia, diante da ocorrência simultânea destes dois institutos em crimes de mesma espécie, de rigor a aplicação apenas do aumento de pena relativo ao crime continuado em relação a todos os delitos, sob pena de bis in idem.

Nesse sentido:

"1-) Apelação criminal. Roubo majorados (concurso de agentes), em continuidade delitiva, e corrupção de menores. Parcial provimento do recurso defensivo para absolver o recorrente do roubo cometido em face da vítima W. e redimensionar as penas. 2-) Materialidade delitiva e autoria dos crimes dos quais foram vítimas S., I. e L. foram comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Delitos que podem ser atribuídos ao apelante. 3-) Quando ao roubo praticado em face do ofendido W., a autoria é duvidosa, impondo-se a absolvição por insuficiência de provas. 4-) Causa de aumento (concurso de agentes) comprovada pela prova oral. Os elementos de prova demonstraram que havia pluralidade de agentes, com nítida divisão de tarefas para a perfeita execução da empreitada criminosa. 5-) O crime de corrupção de menores é formal, de sorte que não exige a comprovação da inocência moral ou efetiva corrupção dos menores envolvidos na prática criminosa, bastando que eles tenham participado ou concorrido para o seu cometimento (Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça). 6-) Penas redimensionadas. Na primeira fase, as penas-base foram fixadas no piso, quatro (4) anos de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa para os delitos de roubo e um (1) ano de reclusão para o crime de corrupção de menor, pois ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, as penas permaneceram no mesmo patamar, nos termos da Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, as penas dos delitos de roubo cometido em face de S. e corrupção de menores, não sofrem alterações, porque ausentes causas de aumento ou diminuição. No que tange ao roubo praticado contra as vítimas I. e L., a pena foi aumentada em 1/3, pela causa de aumento do concurso de agentes, tendo-se cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão e pagamento de treze (13) dias-multa. E, na espécie, ocorreu concurso formal, pois, mediante uma única ação, o recorrente praticou três roubos, atingindo patrimônios distintos, inexistindo crime único. Entretanto, esses delitos são da mesma espécie do anterior (roubo do veículo da vítima S.) e, pelas condições de tempo, espaço temporal diminuto entre um e outro, e lugar, não muito longe uma de outra situação, podem ser tidos como continuação do primeiro. Nesse caso, a orientação dos Tribunais Superiores é no sentido de que se aplica somente o aumento de pena relativo ao crime continuado, excluindo-se o concurso formal das operações. Assim sendo, tendo em vista que o apelante participou de três roubos, um deles em concurso formal, a pena do delito mais grave (roubo majorado) fica aumentada em 1/5, tendo-se seis (6) anos, quatro (4) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão e pagamento de quinze (15) dias-multa. Por fim, existe concurso formal entre um dos roubos e a corrupção, na medida em que, mediante uma única ação, o recorrente praticou ambos os delitos, tendo a corrupção se dado em razão da prática do delito patrimonial. No entanto, no caso, se aplicado o concurso formal, não se faria vigor o disposto no art. 70, parágrafo único: "Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código", logo, optar-se-á pelo cúmulo material, tendo-se sete (7) anos, quatro (4) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão e pagamento de quinze (15) dias-multa. 7-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pela inquestionável periculosidade do apelante, para sua efetiva prevenção geral e especial, além da retribuição e recuperação. 8-) Não há

pronunciamento nos termos do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal. Na omissão, entende-se pelo mais benéfico, recurso em liberdade. Determinada expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado, em virtude de recente decisão no Excelso Supremo Tribunal Federal (6x5).” (TJSP; Apelação Criminal 0078895-29.2017.8.26.0050; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/08/2022; Data de Registro: 15/08/2022) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. LEI N. 13.654/2018. CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DO USO DE ARMA DE FOGO. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. INCIDÊNCIA DE TRÊS MAJORANTES. FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA PREVISTA EM LEI QUE DECORREU DO MERO NÚMERO DE MAJORANTES. VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 443 DESTA CORTE. CRIME CONTINUADO. CONCURSO FORMAL. AUMENTOS CUMULATIVOS. DESCABIMENTO. BIS IN IDEM. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. PROVIMENTO ESTENDIDO AOS CORRÉUS.

1. A Lei n. 13.654/2018 implicou novatio legis in melius apenas ao crime de roubo cometido mediante o emprego de arma imprópria, na medida em que, com relação à arma de fogo, o que ocorreu foi o instituto da continuidade normativo-típica.

2. É certo que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal confere ao juiz, no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, a faculdade - e não o dever - de fazer incidir a causa que mais aumente a pena, excluindo as demais. No entanto, a incidência cumulativa de majorantes demanda fundamentação lastreada em elementos concretos dos autos que evidenciem o maior grau de reprovação da conduta e, em consequência, a necessidade de sanção mais rigorosa. In casu, a aplicação de fração superior à mínima prevista em lei decorreu do mero número de majorantes, o que está em desacordo com a Súmula n. 443 desta Corte.

3. Esta Corte entende que "havendo concurso formal entre dois delitos cometidos em continuidade delitiva, somente incidirá um aumento de pena, qual seja, o relativo ao crime continuado" (AgRg no AREsp n. 1.651.831/GO, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021).

4. No caso em exame, foram cometidos quatro delitos de roubo. As instâncias ordinárias reconheceram a existência de crime continuado quanto aos dois primeiros, e a ocorrência de concurso formal entre as quatro infrações, razão pela qual a pena foi aumentada em 1/6, pela continuidade delitiva e, posteriormente, elevada, novamente em 1/6, em razão do concurso formal. Nesse sentido, mostra-se inequívoca a presença de bis in idem na dosimetria da pena. Embora em delitos cometidos em concurso formal e continuidade delitiva esta Corte afaste o aumento decorrente do art. 70 do Código Penal, fazendo prevalecer apenas aquele previsto no art. 71 do mesmo diploma legal, a peculiar capitulação jurídica dos fatos, realizada na origem, impõe, excepcionalmente, a inversão dessa regra. Assim, fica afastado o aumento de pena relativo ao crime continuado, permanecendo apenas o resultante do concurso formal.

5. Ordem de habeas corpus concedida para fixar o aumento da reprimenda, na terceira fase da dosimetria, em 1/3, e, de ofício, excluir o acréscimo oriundo da continuidade delitiva, redimensionando as penas com extensão de efeitos aos Corréus.” (HC n. 742.148/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

De outra banda, quanto ao corréu Wagner, a autoria é duvidosa.

Para se lançar uma condenação, como é cediço, é imprescindível a certeza ampla de ser o agente o autor do crime que lhe foi atribuído. Se houver qualquer dúvida no espírito do julgador, a absolvição é medida que se impõe, porquanto a liberdade de uma pessoa não pode ser coarctada sem que a acusação seja comprovada por provas exatas e seguras.

Embora as testemunhas policiais tenham relatado que viram indivíduos juntos, em bicicletas, e que eles mudaram a direção ao veres a patrulha policial, e em que pese tenha a testemunha Danilo consignado que foi ao encalço de quatro deles, conseguindo deter dois, sendo um deles o corréu Wagner, nenhuma outra prova foi

produzida sob o crivo do contraditório que demonstre, com segurança, a participação de Vagner nos crimes a ele imputados.

Há nos autos apenas o reconhecimento feito pela vítima J. em solo policial, sendo que este não foi confirmado em Juízo.

As demais vítimas, C. e N., não haviam reconhecido Vagner na delegacia e, em Juízo, somente a vítima C. apontou-o, mas sem demonstrar qualquer certeza em seu reconhecimento.

Outrossim, com o corréu Vagner foi apreendida somente a quantia de R\$10,00, o que somente se deduz do boletim de ocorrência e do depoimento extrajudicial da testemunha policial Danilo, que em Juízo disse não recordar com quem o dinheiro havia sido apreendido.

Frise-se que a inocência do corréu Vagner não é patente.

Todavia, em face do quadro probatório e havendo dúvidas no que pertine à prática do crime descrito na denúncia, sua absolvição é a medida que se impõe, pois antes absolver provável culpado a condenar um inocente.

Assim, firmada a materialidade e a autoria apenas do acusado Pedro Henrique nos crimes previstos no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal, em relação às vítimas C. e N., e ao artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, em relação à vítima J., em continuidade quanto aos demais delitos, passo à dosagem da pena de Pedro Henrique, atentando-me para o critério previsto no artigo 68 do Código Penal.

Atendendo às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o acusado não ostenta maus antecedentes e não há outras razões para elevação da pena-base acima de seu mínimo legal, que fica fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Considerando a situação econômica dos réus, estabeleço o valor de cada dia-multa no mínimo legal, devendo ser corrigido desde a data dos fatos.

Na segunda fase da aplicação da pena, verifico que os delitos foram cometidos em ocasião de calamidade pública. Em que pese a vigência somente até 31 de dezembro de 2020 do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em âmbito federal, verifica-se que o estado de calamidade pública no Estado de São Paulo, decorrente da pandemia do COVID-19, foi reconhecido por meio do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, que ainda se encontra em vigência diante de sucessivas prorrogações. Portanto, em âmbito estadual, mantiveram-se vigentes as normas referentes ao reconhecimento do estado de calamidade pública. A agravante tem caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência. De qualquer forma essa circunstância não pode ser ignorada, pois o isolamento social e a quarentena, em razão da pandemia, facilitam a prática do crime. Impõe-se, portanto, o aumento de pena pelo reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Assim, aumento a pena em 1/6, ficando ela fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor já estabelecido.

Reconheço, outrossim, a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, uma vez que as três vítimas eram pessoas maiores de 60 (sessenta) anos de idade, ficando a pena aumentada em mais 1/6, e fixada em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor já fixado.

Na última fase do cálculo da pena, verifico que os roubos foram praticados com a majorante do concurso de duas ou mais pessoas, devendo ser a pena acrescida de 1/3. Dessa forma, efetuando-se o acréscimo mencionado, fica a pena fixada em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Finalmente, considerando-se que os roubos em que foram vítimas C. e N. foram praticados em concurso formal, aplica-se a regra contida no artigo 70 do Código Penal entre estes. Considerando, ainda, a continuidade decorrente das semelhanças das circunstâncias de tempo, de modo e de lugar, envolvendo os crimes ocorridos nas duas ocasiões descritas na exordial, ou seja, os roubos cometidos contra as vítimas C. e N. e o roubo praticado contra a vítima J., é caso de reconhecimento de crime continuado.

Entretanto, nos termos já expostos anteriormente, deve ser aplicado à hipótese apenas o aumento em relação à continuidade delitiva. Assim, sendo os crimes iguais, aplica-se a pena de somente um deles e aumenta-se de 1/6 até metade. O critério deste aumento é o número de crimes praticados. No caso dos autos, como foram praticados três crimes de roubo, impõe-se o aumento de 1/5 da pena. Assim, a pena passa a ser de 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, no valor já fixado.

Torno essa pena definitiva na ausência de modificadoras.

Na forma do artigo 33 do Código Penal, em razão do montante de pena aplicado, mas observando-se também a gravidade inerente ao delito e as repercussões deste no meio social, tendo em vista que se trata de roubos praticados em concurso de elevado número de agentes e com grave ameaça à pessoa, restando demonstrada especial periculosidade do réu, fixo o regime inicial fechado como regime inicial do cumprimento de pena.

Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por outra espécie de pena diante da quantidade de pena imposta, bem como por terem sido os crimes praticados com grave ameaça à pessoa. Também pelos mesmos motivos, é incabível o sursis.

Finalmente, não há se cogitar da aplicação imediata do disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal nesta seara, vale dizer, sem elementos concretos a respeito do seu comportamento no cárcere, a recomendar a prudência e o bom senso que a questão relacionada à detração penal seja analisada por primeiro pelo Juízo das Execuções.

A lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o Código Penal e não o Código de Processo Penal. A progressão de regime vem, por sua vez, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada a progressão, imprescindível que sejam analisados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o do Juízo das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

Nesse sentido:

"Apelação - Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria bem demonstradas - Testemunho dos agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa - Ré confessa, ademais - Não incidência do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que não preenchidos os requisitos subjetivos - Precedentes - Pena de multa que se corrige - Mínimo erro material do r. juízo em detrimento da apelante - Regime fechado justificado - Impossibilidade de substituição da física por restritiva de direito - Detração - Matéria afeta ao Juízo das Execuções

Criminais - Recurso desprovido, com observação." (TJSP - Ap. Nº 0003591-97.2014.8.26.0577 - 4ª Câmara - Rel. Ivan Sartori - J. 28.04.2015 - grifei)

Deve-se ressaltar, ainda, que a detração neste momento processual causaria a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu PEDRO HENRIQUE BRITO DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, às penas de 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, incidente a correção monetária, por infração ao disposto nos 157, §2º, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal, em relação às vítimas C. e N., e ao artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, em relação à vítima J., em continuidade quanto aos demais delitos, nos termos já expostos, bem como para ABSOLVER o réu VAGNER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, qualificado nos autos, das imputações que lhe foram feitas, com fulcro no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Diante da absolvição de VAGNER, expeça-se Alvará de Soltura Clausulado em seu favor.

Nego ao réu PEDRO HENRIQUE o direito de apelar desta em liberdade, estando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, considerando-se a gravidade dos crimes de roubo, praticados com grave ameaça contra vítimas idosas, em concurso de elevado número de pessoas.

Finalmente, não há qualquer alteração da situação fática ou jurídica que justifique a reconsideração da decisão que decretou a custódia cautelar no presente feito, mormente no momento em que foi proclamado culpado em primeiro grau de jurisdição.

Portanto, verifico que ainda estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo de rigor manter a prisão preventiva, cumprindo-se, outrossim, o disposto no parágrafo único do artigo 316 do mesmo diploma legal.

Recomende-se o réu PEDRO HENRIQUE na prisão em que se encontra.

Ausente demonstração mínima suficiente de prejuízos sofridos pela vítima e não tendo havido pedido para tanto na denúncia, inviabilizando-se o contraditório, deixo de condenar o réu nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo do direito de reparação do ofendido a ser perseguido na esfera cível.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Vicente, 18 de agosto de 2022.

ALEXANDRE TORRES DE AGUIAR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA